

**Algunas notas en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. El rol de la CSJN.
En homenaje al profesor Roberto Punte**

Por Marcela I. Basterra^(**)

1. Introducción

En la actualidad la cuestión relativa a la exigibilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales se presenta en forma muy diferente a la justiciabilidad de los derechos civiles y políticos, tal como reconoce Philippe Texier¹.

Esta diferenciación de criterios ha sido señalada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en los siguientes términos *“los derechos civiles y políticos han sido objeto, en muchos sentidos, de mayor atención, codificación jurídica e interpretación judicial, y se han grabado en la conciencia pública en mucho mayor grado que los derechos económicos, sociales y culturales. Esto se debe a que, a veces, se supone erróneamente que solo los derechos civiles y políticos (es decir, el derecho a un juicio justo, el derecho a la igualdad de trato, el derecho a la vida, el derecho de voto, el derecho a no ser objeto de discriminación, etc.) pueden ser objeto de infracción, de medidas de reparación y de escrutinio jurídico internacional. A menudo se considera que los derechos económicos, sociales y culturales son en la práctica “derechos de segunda clase” inaplicables, no sometidos a los tribunales y que solo se irán cumpliendo “progresivamente” con el tiempo”*².

Como reconoce Bazán³ han existido fuertes posiciones doctrinarias que han catalogado históricamente a los DESCAs como derechos incompletos, simples expectativas, promesas o postulados sin anclaje jurídicamente coactivo.

^(**) Profesora titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires. Presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional.

¹ Texier, Philippe, Exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales en el sistema universal en *Construyendo una agenda para la justiciabilidad de los derechos sociales*. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Biblioteca Jurídica del Instituto Jurídicas de la UNAM, 2017.

² Folleto informativo N°16 (Rev.1) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1996, p. 3, disponible en <http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/folleto-informativo-n-16.pdf>

³ Bazán, Víctor, “Un intento de aporte, fundamentalmente en clave de derecho internacional de los derechos humanos, al documento de Casal sobre ‘La garantía constitucional de los derechos sociales: progresos y dificultades o zonas de tensión’” en Bazán, Víctor y Steiner, Christian

Sin embargo, resulta innegable que los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales han evolucionado desde el solo reconocimiento en instrumentos jurídicos hasta alcanzar una protección judicial efectiva en la jurisprudencia internacional e interamericana.

En nuestro país, la Constitución junto con la normativa internacional sobre derechos humanos conforman un cuerpo jurídico que orienta la vigencia del ordenamiento nacional hacia un idéntico sustrato axiológico, esto es, la protección y la realización de los derechos fundamentales, que son expresión directa de la dignidad humana⁴.

En relación a la justiciabilidad de los DESC en Argentina, la última reforma constitucional de 1994 tuvo gran incidencia. En efecto, la recepción del *corpus iuris* internacional, plasmada en el artículo 75 inciso 22, motivó a los jueces nacionales a adaptar los criterios de igualdad formal a una igualdad real, tutelar los derechos de las personas más vulnerables, reforzar las garantías de acceso a la justicia y exigir al Estado el cumplimiento de políticas públicas destinadas a los sectores más desprotegidos de la sociedad⁵.

En el presente artículo analizaremos la manera en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación comenzó a adoptar los lineamientos de los principales órganos de protección del Sistema de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano para reconocer progresivamente la plena justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

2. La protección de los DESC en la jurisprudencia de la CSJN

2. a. La CSJN y la adecuación de los remedios procesales en materia de salud: El fallo “Asociación Benghalensis” (2000)⁶

Las sentencias de las instancias de grado declararon procedente la acción de amparo interpuesta por la Asociación Benghalensis y otras entidades no gubernamentales que desarrollan actividades para prevenir y erradicar el virus del SIDA. Los actores exigían al Estado Nacional el cumplimiento de las obligaciones de asistir y suministrar medicamentos de modo regular, oportuno y continuo, tal como impone la Ley 23.798⁷.

(Editores), *Justicia constitucional y derechos fundamentales n.º 5. La protección de los derechos sociales. Las sentencias estructurales*, Fundación Konrad Adenauer, Bogotá, Colombia, 2015, p. 60.

⁴ Bazán, Víctor, *El derecho internacional de los derechos humanos desde la óptica de la Corte Suprema de Justicia de Arge*, Estudios Constitucionales, Año 8, Nº 2, 2010, p. 386.

⁵ Altabe de Lértora, Martha Helia. *El proceso de judicialización de los derechos económicos sociales y culturales (DESC) en la República Argentina. El influjo del control judicial de convencionalidad*, Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas, vol. 9 nº17, 2015, p.157.

⁶ A 186 L 34 - "ASOCIACION BENGHALENSIS Y OTROS C/ MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL - ESTADO NACIONAL S/ AMPARO LEY 16986" - CSJN - 01/06/2000 (elDial.com - AA4BD)

⁷ Ley 23.798 publicada en el B.O. el 20/09/1990.

El fallo de primera instancia, luego confirmado por la Sala 1º de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal condenó a la demandada a otorgar los medicamentos requeridos.

La sentencia analiza dos de los obstáculos señalados en materia de justiciabilidad de los DESCAs: a) la adecuación de los medios procesales existentes y, b) el alcance de las prestaciones estatales cuando implican acciones positivas que demandan erogaciones presupuestarias.

Sobre el primer aspecto, el fallo de grado aplicó una interpretación extensiva de la legitimación activa prevista en el artículo 43 de la Constitución Nacional. El magistrado afirmó que la expresión “*afectado*”, que enuncia la disposición constitucional, tiene un sentido amplio que debe concebirse como el interés producto del carácter de usuario, consumidor, o integrante de un colectivo para exigir el pleno respeto a los derechos constitucionales.

La doctrina, con razón, reconoce que “*la posibilidad de actuación del sujeto colectivo determina la exigibilidad del derecho, desde que resulta difícil que las víctimas se presenten individualmente a reclamar la prestación, tanto por impedimentos materiales como por la necesidad de resguardar su intimidad*”⁸.

En relación al segundo punto, las sentencias de grado admitieron que la suscripción de convenios entre el Ministerio de Salud de la Nación y las distintas provincias no podía interpretarse como un traslado de responsabilidad del Estado Nacional a otras jurisdicciones. Además, afirman que “*la demandada parece interpretar que su obligación se agota con la entrega de una dosis, sin asumir, como lo prevé la ley, que su responsabilidad por la provisión se mantiene por todo el período en que los médicos tratantes aconsejen la toma de la medicación*”.

Por su parte, el Alto Tribunal adhirió al dictamen del Procurador General, Dr. Becerra, y confirmó la sentencia, reconociendo que el Estado Nacional no sólo debía abstenerse de interferir en el ejercicio de los derechos individuales, sino que debe, además, realizar prestaciones positivas, de manera tal que el ejercicio de los DESCAs no se tome ilusorio⁹. De esta forma, tal como sintetiza Ronconi¹⁰ a través de este pronunciamiento se confirmó que sobre el aparato estatal rige no sólo la obligación de no entorpecer el goce de estos derechos, sino también realizar acciones positivas para que el ejercicio de los mismos sea efectivo.

La importancia del precedente resulta insoslayable, dado que la interpretación de la Corte Suprema evitó que fuesen relegados los deberes estatales en un ámbito social prioritario como es la salud pública, y de que éstos quedaran

⁸ Abramovich, Víctor y Courtis, Christian. Los derechos sociales como derechos exigibles, Editorial Trotta, Buenos Aires, 2002. p. 140.

⁹ Dictamen Procurador General Dr. Becerra, de fecha 22/02/2009, p. 9.

¹⁰ Ronconi, Liliana M, Derecho a la salud: un modelo para la determinación de los contenidos mínimos y periféricos, Salud colectiva, Buenos Aires, 8(2), Mayo - Agosto, 2012, p. 132.

licuados en una discusión acerca de la distribución competencial entre las jurisdicciones¹¹.

2.b. La tutela del derecho a la salud a través de los instrumentos internacionales: El fallo “Campodónico de Beviacqua” (2000)¹²

Un fallo sumamente importante en materia de exigibilidad es la sentencia de la Corte Suprema en “Campodónico de Beviacqua”¹³. El presente caso se relaciona con la afectación del derecho a la salud del niño A.S.B., quien padecía una grave enfermedad en su médula ósea, la cual requería una costosa medicación para su tratamiento que desde hacía varios años venía siendo suministrada por el Banco Nacional de Drogas Antineoplásicas. No obstante ello, en forma intempestiva, la institución comunicó a la madre del niño que dejaría de suministrarla. Ante el peligro inminente, la familia del joven interpuso un amparo exigiendo al Ministerio de Salud la entrega de la medicación, alegando que se vulneraba su derecho a la vida y a la salud, prerrogativas garantizadas por la Constitución Nacional y diversos tratados internacionales.

En la contestación de la demanda, el Estado afirmó que la entrega del medicamento obedecía a razones humanitarias, ya que la enfermedad no era oncológica, por lo cual no era obligación del instituto cubrir el tratamiento. El requerimiento, según la demandada, debía efectuarse a la obra social del niño, o en su caso, solicitar un subsidio al Estado, que discrecionalmente podría otorgarlo o no, ya que la responsabilidad estatal era simplemente subsidiaria.

La sentencia de primera instancia, luego confirmada por la Cámara, hizo lugar al amparo ordenando al Ministerio de Salud de la Nación mantener la provisión del medicamento, considerando que la interrupción del tratamiento vulnera el derecho a la vida y la dignidad personal protegidos por el bloque de constitucionalidad.

La Corte confirmó las sentencias de grado destacando que los instrumentos internacionales que Argentina ha suscripto obligan al Estado a garantizar el derecho a la vida, sin perjuicio de las obligaciones que deben asumir otras entidades públicas y privadas. El aparato estatal debe cumplir con esos compromisos, y no puede desligarse de esos deberes alegando la inactividad de otras instituciones, máxime cuando está en juego el interés superior del niño.

Además, el Alto Tribunal tuvo en consideración el diseño del sistema nacional de salud, regulado por la Ley 23.661¹⁴, dentro del cual se le reconoce al Ministerio

¹¹ Bazán, Víctor, Los derechos económicos, sociales y culturales en acción: sus perspectivas protectorias en los ámbitos interno e interamericano. Anuario de derecho constitucional latinoamericano, 2005, p 559.

¹² C 823 XXXV R H - "Campodónico de Beviacqua, Ana Carina c/ Ministerio de Salud y Acción Social - Secretaria de Programas de Salud y Banco de Drogas Neoplasicas" - CSJN - 24/10/2000 ([elDial.com - AA625](#))

¹³ C 823 XXXV R H - "Campodónico de Beviacqua, Ana Carina c/ Ministerio de Salud y Acción Social - Secretaria de Programas de Salud y Banco de Drogas Neoplasicas" - CSJN - 24/10/2000 ([elDial.com - AA625](#))

¹⁴ Ley 23.661 publicada en el B.O. el 20/01/1989.

de Salud, en calidad de autoridad pública, la facultad de articular y coordinar los servicios asistenciales que prestan las obras sociales, en el marco de una estructura pluralista y una administración descentralizada que se corresponde con la organización federal de nuestro país. En este contexto, el Estado Nacional, a través del Ministerio específicamente, debe garantizar la regularidad de los tratamientos de salud coordinando sus acciones con las obras sociales y los estados provinciales.

La decisión de suministrar el medicamento que adoptó la autoridad nacional respondió a la urgencia y extrema necesidad del tratamiento para garantizar el derecho a la vida del niño. Por eso, afirmó la Corte que *“la prolongación de ese estado (...) priva de sustento a los planteos de la parte que pretenden negar una obligación de ayuda al menor en defecto de la obra social, toda vez que subsisten al presente las razones ‘exclusivamente humanitarias’ que dieron lugar a la entrega del remedio, las cuales, por otra parte, no pueden ser entendidas sino como reconocimiento de la responsabilidad de la demandada de resguardar la vida del niño”*¹⁵.

Reiterando el criterio del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el Alto Tribunal reconoce que la estructura federal exige que las provincias sean responsables de la tutela de ciertos derechos, pero también es responsabilidad del gobierno federal garantizar la aplicación del PIDESC. En consecuencia, el Estado Nacional no puede desligarse de su deber de amparar la vida y la salud del actor, en el marco de su responsabilidad subsidiaria, sin desobligar tampoco a los gobiernos provinciales.

La interpretación que realizan los magistrados permite desprender conclusiones de gran relevancia jurídica. La Corte asigna al Estado Nacional la responsabilidad a partir de dos factores: el carácter urgente del sistema integrado de salud, según el diseño de la Ley 23.661, y la conducta anterior del Estado de haber suministrado el medicamento al niño hasta la interrupción intempestiva.

Los jueces consideraron que la conducta previa en el cumplimiento de una obligación derivada de un derecho social, limita la discrecionalidad estatal, de modo que, cuando la situación de hecho se mantiene y el nivel de prestación correspondiente empeora o disminuye, pesa sobre el Estado la demostración de razones de mejor protección de un derecho o de necesidad justificable, argumento que debe superar un estricto escrutinio¹⁶.

El Tribunal receptó los estándares fijados por el Comité de DESCAs en un informe específico sobre la situación de Suiza¹⁷, aunque sin analizar las Observaciones generales N° 3 y N° 9 que resultaban las fuentes interpretativas más autorizadas

¹⁵ C 823 XXXV R H - "Campodónico de Beviacqua, Ana Carina c/ Ministerio de Salud y Acción Social - Secretaria de Programas de Salud y Banco de Drogas Neoplásicas" - CSJN - 24/10/2000 (elDial.com - AA625), Op. cit. considerandos 28, 29 y 30.

¹⁶ Abramovich, Víctor y Courtis, Christian, Los derechos sociales como derechos exigibles, Op. cit, p. 160.

¹⁷ Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observaciones finales al informe inicial de Suiza, 1998.

en relación a esta temática¹⁸. Más allá de esta consideración, debemos celebrar que el Tribunal Supremo adoptara los criterios interpretativos de los órganos de protección autorizados en la materia para erigirse así como garante último de los derechos fundamentales.

2.c. El derecho a la salud de las personas con discapacidad

La sentencia de la Corte Suprema en el caso “*R., M. J. s/ insania*”¹⁹ se relaciona con la internación psiquiátrica no voluntaria de una persona declarada insana y sobreseída del delito de homicidio por ser inimputable. Si bien el expediente se elevó para resolver únicamente un conflicto de competencia entre dos jueces nacionales, el debido respeto que merecen los derechos y garantías de raigambre constitucional que se encontraban en juego en el presente caso motivaron a la Corte a realizar una serie de consideraciones de trascendental importancia en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

En este sentido, los magistrados reconocer que las personas con padecimientos mentales sufren una debilidad jurídica estructural que pone en riesgo el pleno y libre goce de sus derechos fundamentales. Ante esta situación, se genera la necesidad de establecer una protección normativa eficaz, tendiente a la rehabilitación y reinserción del paciente en el medio familiar y social en tanto las internaciones psiquiátricas que se prolongan innecesariamente son dañosas y generan, en muchos casos, marginación, exclusión y maltrato. En este contexto, el derecho debe ejercer una función preventiva y tuitiva de sus derechos fundamentales, cumpliendo para ello un rol preponderante de la actividad jurisdiccional.

En consecuencia, se debe reconocer que este colectivo posee un estatus particular, ya que son sujetos con ciertas limitaciones derivadas de su situación de reclusión. Frente a tal circunstancia desigual, la regla debe ser el reconocimiento, ejercicio y salvaguardia especial de esos derechos de los que se derivan los deberes legales del sujeto pasivo, ya sea el Estado o los particulares.

Nuestro país ha adoptado múltiples instrumentos internacionales que sientan principios básicos protectores de las personas en esta situación, los cuales resultan una guía interpretativa para regular el funcionamiento de los sistemas de salud. En este sentido, es importante destacar la adopción por parte de la Asamblea General de la ONU de los “*Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental*”²⁰, la Declaración Universal de Derechos Humanos²¹, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre²², la Convención Americana sobre Derechos

¹⁸ Bazán, Víctor, Los derechos económicos, sociales y culturales en acción: sus perspectivas protectoras en los ámbitos interno e interamericano. Op. cit. p 560.

¹⁹ Competencia Nº 1195. XLII - “R., M. J. s/ insania” - CSJN - 19/02/2008 (elDial.com - AA4518)

²⁰ Adoptados por la Asamblea General de Naciones Unidas mediante la Resolución 46/119, del 17 de noviembre de 1991.

²¹ Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 25.

²² Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo XI.

Humanos²³, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos²⁴ y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales²⁵.

Cabe señalar que este *corpus iuris* internacional ha sido receptado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso "*Víctor Rosario Congo c. Ecuador*"²⁶. Asimismo, en el caso "*Ximenes Lopes c. Brasil*"²⁷ la Corte Interamericana destacó la especial atención que los Estados deben a las personas que sufren discapacidades mentales debido a su particular vulnerabilidad. De esta forma, reconoció que toda persona que se encuentre en esta situación es merecedora de una protección más intensa, en razón de los deberes especiales cuyo cumplimiento por parte de las autoridades estatales es necesario para satisfacer las obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos humanos.

A partir de esta normativa, así como también de la legislación nacional²⁸, la Corte Suprema logra desprender una serie de derechos mínimos específicos para quienes padezcan trastornos psíquicos. Entre estos, debemos destacar el derecho a ser informado sobre su diagnóstico y sobre el tratamiento más adecuado y menos riesgoso, el derecho a un examen médico practicado con arreglo a un procedimiento autorizado por el derecho nacional, el derecho a negarse a recibir un determinado tratamiento o formatos terapéuticos, el derecho a la reinserción comunitaria como un eje de la instancia terapéutica, y el derecho al tratamiento menos represivo y limitativo posible.

En efecto, toda internación involuntaria en los distintos supuestos en que un juez puede disponer un encierro forzoso debe, a la luz de la normativa vigente, sustentarse exclusivamente en el padecimiento de una afección mental susceptible de internación en tanto, en un contexto terapéutico, represente la posibilidad de evitar que se concreten actos dañosos graves, inmediatos o inminentes para esa persona o para terceros. La internación de quienes se encuentren afectados de enfermedades mentales no deberá prolongarse más de lo indispensable y aún evitarla, si pueden prestarle debida asistencia las personas obligadas a la prestación de alimentos.

Siguiendo con la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, en el "*Caso Winterwerp c. Países Bajos*"²⁹, la CSJN reconoce la concurrencia de 3 (tres) requisitos esenciales para garantizar la legalidad del internamiento: a) la

²³ Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 7, 8 y 25.

²⁴ Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 7, 9, 10 y 14.

²⁵ Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 12.

²⁶ Informe 63/99 de la Comisión IDH, "*Caso Víctor Rosario Congo c. Ecuador*", de fecha 13/04/1999.

²⁷ Corte IDH, "*Caso Ximenes Lopes vs. Brasil*". sentencia del 04/07/2006, p. 59.

²⁸ Dentro de esta legislación vigente a la fecha de la sentencia, la Corte Suprema señala el Código Civil de Vélez, las leyes 22.431, 24.901 y 23.592; la Constitución de la provincia de Buenos Aires; la Constitución de la provincia de Catamarca; la Constitución de la provincia de Córdoba; la Constitución de la provincia de Formosa; la Constitución de la provincia de Jujuy y por último, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

²⁹ Corte Europea de Derechos Humanos, "*Caso Winterwerp c. Países Bajos*", sentencia 6301/1973 del 24/10/1979.

enfermedad mental debe haber sido establecida de manera probada; b) el problema debe revestir un carácter o una amplitud legitimante de la internación forzosa y c) la internación no puede prolongarse válidamente sin la persistencia de tal problema.

Resulta imperioso, en este tipo de cuestiones, la realización de un control judicial adecuado acerca de la necesidad de la medida de internación; obligación que debe practicarse en intervalos periódicos razonables para garantizar la legalidad de la medida de seguridad privativa de libertad impuesta. Además, tanto la legislación nacional penal y civil condicionan la internación a un juicio de peligrosidad que la justifique por su gravedad y que, de faltar, tornará a la medida de seguridad impuesta en ilegal.

La Corte comprueba que este examen judicial no existió en el presente caso. Además, observa una serie de circunstancias que se han producido y que afectan la adecuada tutela de los intereses en juego en este tipo de procesos. En efecto, los principios y derechos previamente enumerados resultaron conculcados casi en su totalidad. Del examen de las garantías con que debe contar toda persona al tiempo de su ingreso en una institución psiquiátrica, durante su permanencia y al momento de su egreso, surge que en ninguna de las mencionadas etapas se ha garantizado la protección de los más elementales derechos que le asisten.

El Tribunal entiende que la internación se impuso, inicialmente, en el marco de una causa penal por el delito de homicidio cuando el paciente tenía 14 años. Más allá de que con posterioridad la justicia civil haya tenido intervención, no puede perderse de vista que la restricción de la libertad, lleva más de 25 años. De esta forma, es dable destacar que el paciente ha permanecido privado de su libertad, de manera coactiva, más tiempo incluso del que le habría correspondido *in abstracto* en el supuesto de haber sido condenado a cumplir el máximo de la pena previsto para el delito cometido. En estas condiciones, tanto el principio de proporcionalidad como el propósito de respetar el principio de igualdad, que se buscó con la declaración de inimputabilidad, se ven seriamente comprometidos ya que se muestra como irrazonable que una persona, a la que el Estado no quiere castigar, se vea afectada en sus derechos en una medida mayor de la que le hubiese correspondido de haber sido eventualmente condenada como autor responsable.

Por todas las consideraciones expresadas, la Corte Suprema ordenó a la autoridad correspondiente la realización, con carácter urgente, de un detallado informe científico sobre el estado psicofísico y las condiciones de internación del paciente, con expresa observación a las pautas y principios constitucionales. Como afirma la doctrina, la importancia del fallo resulta insoslayable toda vez que la Corte consolida importantes principios protectorios en materia del derecho a la salud de un grupo históricamente vulnerado, al establecer la responsabilidad estatal indelegable y la especial obligación de extremar medidas para garantizar el respeto de sus derechos fundamentales³⁰.

³⁰ Ronconi, Liliana y Montes, Lucía “La recepción de la jurisprudencia de la Corte IDH en casos de derechos sociales resueltos por la Corte Suprema de Justicia Argentina” en Moreira Maués,

2. d. El derecho a la vivienda adecuada y las personas en situación de extrema vulnerabilidad: El fallo “Q.C.S.Y” (2012)³¹

En este precedente, la actora, por derecho propio y en representación de su hijo menor de edad, quien sufría una discapacidad producida por una encefalopatía, interpuso una acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argumentaba que la conducta de la demandada vulneraba sus derechos a la salud, dignidad y vivienda, ya que se le impedía acceder a los programas gubernamentales en materia de vivienda y tampoco se le proporcionaban alternativas para salir de la "situación de calle" en la que se encontraban.

La sentencia del Juzgado de primera instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, al igual que la Cámara, hizo lugar a la demanda, obligando a la administración pública a proveer un subsidio que le permita a la actora abonar en forma íntegra un alojamiento en condiciones dignas de habitabilidad. Sin embargo, el Superior Tribunal de CABA revocó la decisión.

La Corte Suprema emitió una sentencia de suma relevancia en materia de exigibilidad judicial de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. En primer lugar, reconoció que éstos no son meras declaraciones, sino normas jurídicas operativas con vocación de efectividad. Afirmó que los derechos humanos son reconocidos por la Constitución Nacional para que éstos resulten efectivos y no ilusorios, la reglamentación tiene como finalidad darles el contenido que la ley fundamental les asigna. La operatividad que caracteriza a estas normas significa que, en principio, su implementación requiere de una ley del Congreso o de una decisión del Poder Ejecutivo que provoque su implementación.

Por esta razón, no desconoce las facultades que la Constitución le asigna tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo, en el ámbito de sus respectivas competencias, para implementar los programas o alternativas destinadas a hacer operativo el derecho a la vivienda y al hábitat adecuado.

Además, la Corte afirma que el reconocimiento de estos derechos impone a los Estados obligaciones de hacer, con operatividad derivada, las cuales están sujetas al control de razonabilidad por parte del Poder Judicial. El juez Petracchi³² enfatizó la justiciabilidad del derecho a la vivienda al sostener que cuando la Constitución *“reconoce derechos, lo hace para que éstos resulten efectivos y no ilusorios, sobre todo cuando se encuentra en debate un derecho humano fundamental”*.

Antonio y Baía Magalhães, Breno (Organizadores), *O controle de convencionalidade na América Latina: experiências comparadas* Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2018.

³¹ CSJN, “Q.C.S.Y c/ Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ amparo”, sentencia del 24/04/12.

³² CSJN, “Q.C.S.Y c/ Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ amparo”, op. cit., voto del Dr. Petracchi, considerando 9.

Los funcionarios que deciden las políticas públicas deben tener en cuenta los principios de igualdad democrática y de diferencia con finalidad tuitiva de los sectores excluidos. Además, debe reconocerse una garantía mínima del derecho fundamental que constituye una frontera a la discrecionalidad de los poderes públicos. Para que esto sea posible, debe acreditarse una afectación de la garantía, es decir, una amenaza grave para la existencia misma de la persona. La Corte entiende que estos extremos se encuentran acreditados en el caso concreto ya que es difícil imaginar una situación fáctica más desesperante: la discapacidad del niño, junto con la situación de pobreza en la que se encuentra la familia genera una situación de vulnerabilidad estructural.

Adicionalmente, alegó que resulta evidente que el esfuerzo estatal realizado para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales no es suficiente o adecuado, ya que ni siquiera se atendió a las mínimas necesidades que la condición del grupo familiar requiere. Si bien puede admitirse que no hay una única manera de responder al derecho de vivienda, lo cierto es que las alternativas implementadas por la demandada no implicaron una respuesta adecuada, definitiva y acorde a las extremas circunstancias que debe afrontar la recurrente.

Por las consideraciones expuestas, condenó al Gobierno de la Ciudad a garantizar a la actora, aún en forma no definitiva, un alojamiento con condiciones edilicias adecuadas a la patología que presenta el niño, sin perjuicio de contemplar su inclusión en algún programa de vivienda en curso o futuro para la solución permanente de la situación de excepcional necesidad planteada.

Estas consideraciones no implican que todos los ciudadanos pueden solicitar por vía judicial la provisión de una vivienda, ya que esta facultad es atribuida por la Constitución Nacional a los restantes poderes. Sin embargo, la doctrina de la CSJN en este precedente reconoce que estos derechos fundamentales están sujetos a un análisis de razonabilidad por los magistrados. En este sentido, afirma que se deben atender a las garantías mínimas indispensables para que una persona sea considerada como tal en situaciones de extrema vulnerabilidad, es decir existen ciertos pisos mínimos del derecho fundamental que constituyen una frontera a la discrecionalidad de los poderes públicos³³.

En definitiva, el presente caso se califica como un pronunciamiento medular en la jurisprudencia argentina sobre exigibilidad del derecho a la vivienda digna³⁴.

2. e. La CSJN y el análisis sobre los estereotipos de género en el acceso al mercado laboral: El fallo “Sisnero” (2014)³⁵

³³ Pérez, Agustina. Tensiones y desafíos en torno a la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales en Argentina a la luz de los acontecimientos recientes. Revista Latinoamericana de Derechos Humanos, vol. 28, II Semestre de 2017, p. 165.

³⁴ Benente, Mauro y Aguirre, Matías Guillermo, “La exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Un estudio desde la perspectiva de la gubernamentalidad” en Thea, Federico Gastón (Comp.) Derecho a la vivienda y litigio estructural, Edunpaz, Argentina, 2017, p. 141.

³⁵ S.932.XLVI – “Sisnero, Mirtha Graciela y otros c/ Taldelva SRL y otros s/ amparo” – CSJN – 20/05/2014 (elDial.com - AA874A)

La presente sentencia de la Corte Suprema se vincula con una situación de inequidad de género en la etapa de acceso al empleo, que motivó el debate sobre el alcance del derecho constitucional a la igualdad y a la no discriminación de las mujeres en la selección de personal para ocupar puestos de trabajo.

Las actoras interpusieron dos pretensiones; una individual y otra colectiva. En relación con la primera, alegaron la violación del derecho a la igualdad y a la no discriminación en razón del género, a raíz de la imposibilidad de la señora Sisnero de acceder al trabajo de chofer en las empresas demandadas, pese a haber cumplido con todos los requisitos de idoneidad solicitados. En cuanto a la pretensión colectiva, argumentaron -con razón- la vulneración de los derechos en cuestión, ante la probada falta de contratación de choferes mujeres en el transporte público de pasajeros por parte de las empresas operadoras de Sociedad Anónima del Estado de Transporte Automotor.

Siguiendo esa línea argumental, solicitaron: (i) el cese de la discriminación por razones de género, (ii) la incorporación de Mirtha Sisnero como chofer de colectivo y (iii) el establecimiento de un cupo de puestos para ser cubiertos exclusivamente por mujeres, hasta que la distribución total refleje una equitativa integración de los géneros en el plantel de choferes de las demandadas.

La Cámara hizo lugar al amparo, ordenando a las empresas de transporte a contratar mujeres hasta cumplir con el 30% de cupo femenino de la planta de choferes existentes, y en caso de incumplimiento, a abonar un salario a la mujer que estuviera en primer lugar de la lista de aspirantes de la Autoridad Metropolitana de Transporte.

La Corte Suprema de Justicia de Salta revocó el pronunciamiento por entender que no se configuraba caso judicial, toda vez que no se demostró que las empresas convocaran sólo a hombres para cubrir sus puestos vacantes.

El caso llegó a la Corte Federal, que deja sin efecto la sentencia impugnada reenviando la causa a la Corte provincial para que dicte un nuevo pronunciamiento teniendo en cuenta la discriminación alegada y debidamente probada. En forma complementaria, destacó que los principios de igualdad y de prohibición de toda discriminación resultan elementos estructurales del orden jurídico constitucional argentino e internacional.

En este sentido, sentó un importante estándar al establecer que en el marco de las relaciones laborales, las obligaciones en materia de igualdad y no discriminación recaen sobre todos los poderes del Estado y también sobre los particulares, tal como lo entendió la Corte Interamericana de Derechos Humanos³⁶. Además, afirmó que estas obligaciones se extienden tanto respecto de aquellos casos en que la situación discriminatoria es el resultado de las acciones y omisiones de los poderes públicos como cuando es el resultado del comportamiento de los particulares.

³⁶ Corte IDH, Opinión Consultiva Opinión Consultiva OC-18/03 “Condición jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados” de fecha 17/09/2013”, párr. 104.

Por otro lado, reconoció que la justificación de cualquier decisión de contratación en perjuicio de las mujeres deberá estar despojada de estereotipos, ratificando así la doctrina de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en el caso “*Mississippi University for Women v. Hogan*”³⁷. Las empresas demandadas plantearon, como defensa, que la actora carecía de experiencia en el ejercicio de ese oficio, alegato que para los magistrados responde a un estereotipo de género por el cual durante años se ha excluido históricamente a las mujeres de este oficio.

Los magistrados ratificaron la doctrina expuesta en el caso “*Pellicori*”³⁸ en el que se afirmó la discriminación no suele manifestarse de forma abierta y claramente identificable, por lo cual la prueba con frecuencia resulta compleja. Habitualmente, la discriminación es una acción más presunta que patente, y difícil de demostrar ya que normalmente el motivo subyacente a la diferencia de trato está en la mente de su autor. Además, en relación al estándar probatorio aplicable a estas situaciones, destacó quien invoca un acto discriminatorio, es suficiente con la acreditación de hechos, que *prima facie* evaluados, resulten idóneos para inducir su existencia, caso en el cual corresponderá al demandado, a quien se reprocha la comisión del trato impugnado, la prueba de que éste tuvo como causa un motivo objetivo y razonable ajeno a toda discriminación.

Siguiendo la misma línea argumental, el Alto Tribunal hace referencia a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que dispone que los Estados Parte adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en materia de empleo, a fin de asegurar el derecho de acceso a iguales oportunidades, inclusive a la aplicación de los mismos criterios de selección. Igualmente, destacó lo dispuesto por el artículo 4º el cual declara que estas medidas tienen como finalidad acelerar la participación en condiciones de igualdad de la mujer en el ámbito político, económico, social, cultural y civil. En tal sentido, se pronuncia el Convenio N° 111 de la OIT relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación³⁹.

Por último, la Corte determinó que tanto el Estado como los particulares están obligados a adoptar medidas de acción positiva en la esfera del empleo para contrarrestar la segregación por género y revertir los patrones socioculturales que la explican. Con excelente criterio interpretativo del derecho internacional, el Alto Tribunal determinó que correspondía revocar la sentencia apelada, en concordancia con lo dictaminado por la Procuradora General.

2. f. El análisis sobre el derecho a la educación de una niña con discapacidad en la doctrina de la CSJN

³⁷ Corte Suprema de los Estados Unidos, “*Mississippi University for Women v. Hogan*”, 458 U.S. 718, de fecha 01/06/1982.

³⁸ P. 489. XLIV. – “*Pellicori*, Liliana Silvia c/ Colegio Público de Abogados de la Capital Federal s/ amparo” – CSJN – 15/11/2011 (elDial.com - AA713B)

³⁹ Basterra, Marcela I. Avances y desafíos de los derechos de género. Evaluación de las acciones positivas. Jurisprudencia Argentina. Crovi, Luis (Dirr.). Editorial Abeledo Perrot. Buenos Aires, junio de 2018, p. 13.

Corresponde ahora abordar la sentencia que surge del fallo “A., M. L. por su hija menor c/ OSDE s/ ley de medicina prepaga”⁴⁰, en el que la Corte Suprema de Justicia desarrolla importantes consideraciones en un caso donde se debatía el derecho a la educación de una niña con Síndrome de Down.

La madre, en representación de su hija menor de edad, interpuso un amparo solicitando se condene a la empresa de medicina prepaga OSDE, a abonar la cobertura correspondiente a la escolaridad de la niña en el Colegio San Jorge de Chacras de Coria, Provincia de Mendoza conforme con los aranceles actualizados por el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación.

Los magistrados de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza revocaron la decisión de primera instancia, que había declarado inadmisibile la demanda incoada, y en consecuencia, ordenaron a la demandada que abone las sumas requeridas para satisfacer el derecho a la educación de la niña. Los jueces consideraron que OSDE no había demostrado la existencia de un establecimiento educacional público adecuado para recibir a la joven. Además, estimaron que debía prevalecer la contención socio-afectiva de la niña, a efectos de no desnaturalizar el régimen protectorio de las personas con discapacidad y, en ese sentido, ponderaron que concurría al citado colegio desde sala de 2 años y que tanto la médica pediatra, como la psicopedagoga habían solicitado que su escolarización continuara en el mismo instituto.

La Corte Suprema, siguiendo la doctrina sentada en el caso “R., D. Y otros c/ Obra Social del Personal de la Sanidad s/ amparo”⁴¹, ratificó diversas pautas respecto de la carga probatoria que pesa sobre las partes en juicios de esta naturaleza. En este sentido, expresó que el agente del servicio de salud es quien debe ocuparse concretamente de probar una alternativa entre sus prestadores que proporcione un servicio educativo análogo al que se persigue en la causa, así como demostrar la exorbitancia de la elección paterna.

Sobre este punto, consideró que asiste razón a la demandada pues la elección de los progenitores resultaba infundada al destacar que el instituto escogido es uno de los más costosos del ámbito educativo provincial y que, después de haber hecho concurrir allí a la niña por más de cinco años, intempestivamente solicitaron a OSDE el pago de los aranceles escolares.

Para la Corte, el tribunal de alzada omitió toda ponderación de los testimonios de las expertas en psicopedagogía que dan cuenta de la posibilidad de que la niña asistiera a las escuelas públicas provinciales. Tampoco efectuó referencias al informe que, en igual sentido, emitió la Dirección General de Educación Especial de la citada provincia, ni evaluó que la empresa se había hecho cargo de las prestaciones de apoyo escolar e integración a través de tratamientos psicopedagógicos, neurolingüística y terapia ocupacional.

⁴⁰ FMZ 14876/2015 – “A., M. L. por su hija menor c/ OSDE s/ ley de medicina prepaga” – CSJN – 29/03/2018 (elDial.com - AAA8CC)

⁴¹ CSJN, “R., D. Y otros c/ Obra Social del Personal de la Sanidad s/ amparo”, sentencia del 27/11/2012.

La Corte concluye que, dadas las falencias que exhibe el fallo apelado, corresponde disponer su descalificación con arreglo a la conocida doctrina en materia de arbitrariedad de sentencias. En consecuencia, hizo lugar al recurso de queja interpuesto por la demandada y declaró procedente el recurso extraordinario, dejando sin efecto la sentencia impugnada.

2. g. La Corte Suprema se erige como garante de derechos fundamentales: El fallo “*Institutos Médicos Antártida*” (2019)⁴²

Por último, me interesa destacar un fallo de la Corte Suprema de Justicia sumamente elogiable en el cual los magistrados garantizan el derecho a la salud de una persona en situación de extrema vulnerabilidad, a partir de una sólida interpretación del *corpus iuris* internacional.

El actor solicitó la declaración de inconstitucionalidad del régimen de privilegios concursales previsto en la Ley de Concursos y Quiebras⁴³ y, consecuentemente, la verificación de su crédito con carácter prioritario en la quiebra de la empresa “*Institutos Médicos Antártida*”.

La Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial revocó la sentencia de primera instancia que había declarado la inconstitucionalidad del régimen de privilegios concursales previsto en la citada normativa. En consecuencia, le asignó al crédito carácter quirografario dejando sin efecto también el pronto pago dispuesto por el magistrado de grado.

Para así decidir, la alzada afirmó que no era el derecho a la vida, a la salud ni a la dignidad de la parte actora lo que se encontraba en juego, sino que se trataba de un derecho patrimonial transmisible y renunciable, originado en una obligación pecuniaria, a la que el legislador no le había reconocido preferencia de cobro.

Es importante destacar que el crédito cuestionado deriva de una indemnización concedida por la mala praxis médica ocurrida durante el nacimiento del actor que le provocó una parálisis cerebral con 100% de incapacidad irreversible y una afección de todos los órganos. Como consecuencia de ello, el niño padece lesiones cerebrales gravísimas, parálisis en los cuatro miembros que le impide movilizarse y un retraso en el crecimiento.

Ante esta situación, en 1998 los padres interpusieron acción civil por daños y perjuicios contra el médico Dr. López Mautino, el sanatorio Institutos Médicos Antártida y la Obra Social del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte (OSMATA), la cual fue declarada admisible tanto en primera instancia como en cámara. Ante la quiebra de Institutos Médicos Antártida, decretada el 10 de febrero de 2003, los beneficiarios solicitaron la verificación de su crédito pero todos los deudores se encontraban en estado de insolvencia.

⁴² CSJ 344/2011 (47-I)/CS1 – “*Institutos Médicos Antártida s/ quiebra s/ inc. de verificación (R.A.F. y L.R.H. de F.)*” – CSJN – 26/03/2019 (elDial.com - AAB1A8)

⁴³ La actora solicitó específicamente la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 239, primer párrafo, 241, 242 parte general y 243 parte general e inc. 2° de la Ley 24.522, publicada en el B.O. el 09/08/1995.

En su decisión, la Corte Suprema destaca que el joven lleva 28 años transitados con una incapacidad total y sin cobrar la totalidad de su crédito reconocido por sentencia judicial firme. La falta de recursos económicos para solventar los tratamientos médicos agravó considerablemente su estado de salud generando pérdida de la visión y del habla, debiendo ser alimentado con una sonda gástrica y sufriendo recurrentes complicaciones médicas.

Ante este particular contexto fáctico, el Alto Tribunal analizó si las normas internacionales invocadas por los recurrentes, en especial la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, alcanzan a la situación de extrema vulnerabilidad en que se encuentra la actora como titular de un crédito en el marco de un proceso universal y, en su caso, si alteran la preferencia de cobro establecida en la Ley de Concursos y Quiebras. Es decir, si el crédito cuestionado debe ser verificado con rango quirografario o privilegiado y, en este último caso, qué orden de preferencia en el cobro tiene frente a otros privilegios.

Los magistrados, reiterando su doctrina en el caso "*Pinturas y Revestimientos aplicados SA*"⁴⁴, destacaron que el régimen de privilegios previsto en la ley 24.522 debe ser integrado con las disposiciones previstas en los instrumentos internacionales que fueron incorporados a nuestro sistema jurídico con rango superior a las leyes, a partir de la reforma constitucional de 1994.

En este sentido, afirman que la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce el derecho de toda persona "*a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios*"⁴⁵. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, específicamente en los artículos 11 y 12, consagra "*el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia (...) a una mejora continua de las condiciones de existencia*" asumiendo los Estados Partes la obligación de tomar las medidas apropiadas para asegurar su efectividad, y el derecho "*al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental*". Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece el derecho de todo niño "*a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado*"⁴⁶. Además, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad estatuye que los Estados Partes se obligan a adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos.

A pesar de que el privilegio contemplado en la Ley de Concursos y Quiebras solo puede resultar de una disposición legal, la Corte entiende que en el caso se presenta una situación excepcional de absoluta vulnerabilidad que no puede desatenderse en orden a las exigencias de los tratados internacionales citados.

⁴⁴ P. 589. XLVI. – "Pinturas y Revestimientos aplicados SA s/ quiebra" – CSJN – 26/03/2014 (elDial.com - AA8625)

⁴⁵ Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 25.

⁴⁶ Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 19.

Resulta imperativo ofrecer una satisfactoria protección jurídica de la vida y de la salud de la actora, que sea respetuosa de la dignidad que es inherente al ser humano y que no signifique una demora que desnaturalice y torne ilusoria la reparación del derecho irreversiblemente dañado.

De esta forma, los jueces admitieron que a pesar de no existir una norma específica que permita resolver la cuestión planteada en el caso, era posible sostener la inconstitucionalidad de las normas concursales y crear por vía judicial un privilegio para el actor. Para ello, apelaron a diversos fundamentos jurídicos convergentes, en su mayoría provenientes del texto constitucional o de los tratados internacionales de derechos humanos, dentro de los cuales se destaca principalmente la dignidad humana⁴⁷.

La extrema situación de vulnerabilidad del joven, sumado a la falta de recursos económicos para afrontar los tratamientos médicos necesarios, afectaron su derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental. Por eso, teniendo en consideración la especial protección que los instrumentos internacionales le otorgan a la víctima, la Corte declaró inconstitucionales las normas concursales cuestionadas.

En definitiva, teniendo en consideración los derechos humanos reconocidos tanto por la Constitución Nacional como por las convenciones internacionales mencionadas, la extrema situación de vulnerabilidad de la actora y la naturaleza del reclamo efectuado -que tiene por objeto satisfacer sus derechos esenciales-, llevaron al Tribunal a concluir que el crédito en cuestión debe estar resguardado por un privilegio que lo coloque en un plano superior al de los demás créditos privilegiados.

En consecuencia, en concordancia con el dictamen de la Procuradora General de la Nación, la Corte resolvió declarar la inconstitucionalidad de los artículos mencionados y ordenar que se verifique a favor de la actora su crédito con privilegio especial prioritario a cualquier otro privilegio. La importancia del precedente resulta insoslayable toda vez que el Alto Tribunal modificó un cuestionable criterio, sentado en el fallo "*Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia s/ quiebra s/ incidente de verificación de crédito por L.A.R. y otros*"⁴⁸, mediante el cual se había denegado la petición a una joven que se encontraba en una situación fáctica similar.

3. Los nuevos desafíos para el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales

El activismo judicial ha logrado fortalecer la exigibilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, reconociendo que los mismos poseen un núcleo mínimo que no puede ser ignorado por los poderes estatales,

⁴⁷ Lafferriere, Jorge Nicolás, Dignidad humana, equidad y prioridad de cobro en una quiebra. Comentario a la sentencia "*Institutos Médicos Antártida*" de la Corte Suprema argentina, Revista Internacional de Derechos Humanos, Vol. 10, No. 2, 2020, p. 236.

⁴⁸ 8283/2006 – "*Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia s/ quiebra s/ incidente de verificación de crédito por L.A.R. y otros*" – CSJN - 06/11/2018 ([elDial.com - AAAD57](https://elDial.com/AAAD57))

y destacando la protección especial y prioritaria que merecen los grupos más vulnerables. Asimismo, en múltiples sentencias se ha declarado la importancia de adoptar medidas destinadas a satisfacer esta categoría de derechos, así como también se ha sentenciado la inconstitucionalidad de las políticas regresivas⁴⁹.

Sin embargo, la casuística de los tribunales nacionales nos demuestra que, en la mayoría de los casos, para garantizar el ejercicio efectivo de los DESCAs no resulta suficiente habilitar la instancia judicial y obtener una sentencia que declare la violación al derecho invocado. En general, la vulneración de estos derechos plantea problemáticas que involucran el diseño e implementación de políticas públicas, en las que participan una variedad de actores, demandando una intervención más compleja que no se agota con una simple orden judicial, de ejecución inmediata⁵⁰.

Los desafíos en el constitucionalismo actual no consisten ya en debatir sobre la posible afectación a un derecho económico, social, cultural y ambiental en sede judicial, sino en determinar cuáles son los mecanismos y dispositivos idóneos para solucionar cada caso en cuestión.

Por ello, los tribunales nacionales consideraron necesario repensar las clásicas estrategias litigiosas, de forma tal de implementar novedosos remedios judiciales que sean acordes y apropiados para revertir la vulneración de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales⁵¹.

Así, se ha apelado a la creación de espacios de diálogo, la instauración de mesas de trabajo o la convocatoria a audiencias públicas. También, se han implementado mecanismos de monitoreo de cumplimiento de sentencias, liderados por la magistratura o por instituciones públicas, como el Defensor del Pueblo⁵². Adicionalmente, se han designado peritos técnicos o auditores ajenos a las partes para que monitoreen la implementación de las acciones tendientes a la satisfacción de los derechos.

A continuación, analizaremos el fallo “*Villa La Dulce*”⁵³ el cual simboliza la implementación una de las estrategias mencionadas anteriormente.

⁴⁹ Filippini, Leonardo G y Rossi, Julieta, “El derecho internacional en la justiciabilidad de los derechos sociales en Latinoamérica”, en Arcidiácono, Pilar; Espejo Yaksic, Nicolás y Rodríguez Garavito, César (coords.), *Derechos sociales: justicia, política y economía en América Latina*, Bogotá, Siglo del Hombre Editores, 2010, p. 140.

⁵⁰ Fairstein Carolina, Kletzel, Gabriela y García Rey, Paola “En busca de un remedio judicial efectivo: nuevos desafíos para la justiciabilidad de los derechos sociales”, en Arcidiácono, Pilar, Espejo, Nicolás y Rodríguez Garavito, César (eds.), *Derechos sociales: justicia, política y economía en América Latina*, Op. cit. p. 230.

⁵¹ Abramovich, Víctor y Courtis Christian, *El umbral de la ciudadanía. El significado de los derechos sociales en el Estado social constitucional*, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2006, p. 32.

⁵² Pérez, Agustina, *Tensiones y desafíos en torno a la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales en Argentina a la luz de los acontecimientos recientes*. Op. cit. p.167.

⁵³ Juzgado Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires N° 5, “*Agüero, Aurelio Edivigio y otros contra GCBA sobre amparo (Art. 14 CCABA)*”, sentencia de homologación del 18/12/2003.

3. a. El caso “Villa La Dulce”: el funcionamiento de los espacios de diálogo

El conflicto de los vecinos en “Villa La Dulce”, nos demuestra cómo la implementación de estrategias jurídicas innovadoras, a partir de la construcción de mesas de diálogo, permitió arribar a un acuerdo entre las partes. En este proceso de exigibilidad política y jurídica del derecho a una vivienda adecuada, se evidencia las fortalezas de la articulación entre actores institucionales y organizaciones sociales en la lucha por el goce y ejercicio de los derechos humanos⁵⁴.

El caso se inició en el año 2000 cuando ciento ochenta (180) grupos familiares fueron desalojados del predio que habían ocupado. Ante esta situación, distintos actores sociales, como la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, la Asesoría Tutelar en lo Contencioso Administrativo y la Pastoral Social del Arzobispado de Buenos Aires, intervinieron en el conflicto para iniciar un espacio de diálogo con el Gobierno de la Ciudad. De esta forma, se desarrollaron múltiples encuentros entre los vecinos y distintas áreas del gobierno local para mejorar las condiciones habitacionales de las familias. Finalmente, en noviembre de 2001 los partes firmaron un acuerdo mediante el cual el Ejecutivo local se comprometía a desarrollar un proyecto de autoconstrucción de viviendas.

Ante el incumplimiento del gobierno local, los vecinos con el patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales, iniciaron una acción de amparo colectivo exigiendo la satisfacción del derecho a la vivienda. En 2003, se homologó un nuevo acuerdo obtenido extrajudicialmente a través del cual el gobierno se obligaba a construir las viviendas y a desarrollar una línea de crédito accesible para que las familias pudieran adquirirlas posteriormente. Los compromisos estatales fueron incumplidos hasta el año 2008 en que finalmente el gobierno local de ese momento, concluyó con la construcción de las viviendas.

La doctrina reconoce que el proceso judicial *“funcionó como un marco que habilitaba una interlocución continua entre los afectados, las instituciones que les brindaron apoyo jurídico y político y las autoridades responsables de satisfacer los derechos en juego. Esto fue así porque en el desarrollo de la vía judicial hubo permanentes negociaciones extrajudiciales cuyos resultados se fueron incorporando a la causa como mecanismo de garantía para los vecinos”*⁵⁵.

Esta experiencia nos permite comprender los múltiples desafíos que se presentan en relación a la exigibilidad política y jurídica de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y al mismo tiempo, innovar en la manera de abordar las dificultades que se presentan en esta materia. En efecto, la participación de organizaciones civiles y actores políticos relevantes en espacios de diálogo se convierte en una estrategia adecuada para garantizar derechos que, en ciertos casos, son negados en sede judicial. El conflicto del

⁵⁴ Kletzel, Gabriela, y Royo Laura. Una experiencia de exigibilidad jurídica y política del derecho a la vivienda: el caso de los vecinos de Villa La Dulce”, Documentos del Centro de Estudios Legales y Sociales, 2008.

⁵⁵ Fairstein, Carolina, Kletzel, Gabriela, Garcia Rey Paola, “En busca de un remedio judicial efectivo: nuevos desafíos para la justiciabilidad de los derechos sociales”, Op. cit. p. 42.

caso “*La Dulce*” nos demuestra que se vuelve central profundizar espacios de articulación sistemática con la esfera política para lograr la gestión de medidas públicas que aseguren la satisfacción de derechos fundamentales.

3. b. Las audiencias públicas y el fortalecimiento del constitucionalismo dialógico

Como mencionamos anteriormente las audiencias públicas suelen ser otras de las herramientas legales a las que recurren los jueces a fin de fortalecer el diálogo entre las partes, de forma tal de arribar a soluciones integrales.

De conformidad con la Acordada 30/2007 de la Corte Suprema de Justicia⁵⁶, la celebración de estos actos potencia la participación ciudadana y la difusión pública, fortaleciendo la eficacia y objetividad de la administración de justicia. Es importante destacar la importancia de las mismas, toda vez que se convierten en una herramienta de suma relevancia para delimitar y precisar, en casos complejos, el marco de debate del proceso judicial.

Este instrumento jurídico permite a los jueces escuchar e interrogar a las partes, para recoger la información necesaria que posibilite una solución acorde a la naturaleza del conflicto que se debate en cada caso. Asimismo, es necesario enfatizar el impacto que éstas tienen en el fortalecimiento del vínculo del Poder Judicial con las instituciones ciudadanas en el desarrollo del constitucionalismo dialógico. Como destaca Gargarella⁵⁷, esta práctica es utilizada frecuentemente por los tribunales superiores en América Latina ante litigios de tipo estructural, los cuales involucran problemas públicos de gran relevancia.

El fallo de la Corte Suprema en el caso “*Matanza-Riachuelo*” en 2008 demuestra claramente el valor de las audiencias públicas como mecanismo procesal idóneo en esta materia. El precedente se relaciona con la histórica contaminación generada por el riachuelo y la inacción de las autoridades gubernamentales para implementar una adecuada política ambiental y sanitaria. A raíz de los daños y perjuicios sufridos, los vecinos afectados demandaron al Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y diversas empresas.

En el marco del proceso judicial, el Supremo Tribunal convocó a las partes a una serie de audiencias públicas, junto con organizaciones civiles como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Además, designó distintos peritos independientes que deberían hacer un informe sobre la factibilidad del “*Plan de saneamiento del riachuelo*” que debieran presentar el Estado Nacional, en conjunto con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y de la CABA.

Finalmente, luego de oír la opinión de diversos expertos, el Supremo Tribunal determinó que las distintas jurisdicciones demandadas eran responsables por la prevención y recomposición del daño ambiental causado. La sentencia adquirió

⁵⁶ Corte Suprema de Justicia, Acordada 30/2007 adoptada el 05/11/2007

⁵⁷ Gargarella, Roberto (comp.), Por una justicia dialógica: El Poder judicial como promotor de la deliberación democrática, Op. cit. p. 12.

una importancia trascendental en relación al derecho a la salud y al medio ambiente sano⁵⁸. Además, la apertura de espacios de diálogo y la participación de los diferentes actores involucrados, se presentó como una de las características centrales del proceso judicial⁵⁹.

La Corte, aplicando un elogiado activismo judicial, intentó resolver los problemas de salud, carencia de agua potable y emergencia habitacional que afectaban a los vecinos. De esta forma, aplicó medidas de carácter político, alejándose de su tradicional rol procesal, y estableció un conjunto de medidas para que apliquen los distintos niveles de gobierno demandados.

La importancia de la sentencia radica en que trasciende los efectos de las partes y se proyecta hacia toda la comunidad, lo cual no implica que el pronunciamiento tenga efectos *erga omnes*. La importancia es que la Corte se constituye como un poder institucional capaz de construir una política pública en torno a la contaminación del riachuelo. Entre las conclusiones a las que arribó el Alto Tribunal, se destaca la obligación de implementar el plan estratégico que repare el daño ambiental y que tiene la ambiciosa finalidad de convertirse en una política de Estado para satisfacer el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado⁶⁰.

4. Conclusiones

A lo largo del presente artículo pudimos comprobar que los obstáculos tradicionalmente señalados para negar la exigibilidad judicial de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales responden a una visión jurídica sesgada. Por el contrario, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha concluido que los DESCAs resultan plenamente exigibles en tanto involucran normas jurídicas operativas con vocación de efectividad, imponiendo al Estado obligaciones de hacer, que están sujetas al control de razonabilidad por parte del Poder Judicial.

Por otro lado, es posible concluir que en ciertos supuestos, el ejercicio efectivo de estos derechos no se garantizará únicamente con una sentencia condenatoria sino que requerirá reestructurar las herramientas y mecanismos jurídicos tradicionales. Por eso, se vuelve indispensable realizar una reflexión crítica sobre la potencialidad y conveniencia de implementar nuevas estrategias que permitan garantizar un ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, con especial atención a los sectores que presentan mayores niveles de vulnerabilidad social.

⁵⁸ Bergallo Paola, “La causa Mendoza: una experiencia de judicialización cooperativa sobre el derecho a la salud” en Gargarella, Roberto (comp.), *Por una justicia dialógica: El Poder judicial como promotor de la deliberación democrática*, op. cit., p. 258.

⁵⁹ Barrera, Leticia y Sáenz, Jimena. Corte Suprema y participación ciudadana: reflexiones a partir de una audiencia pública de la Corte argentina, *Revista Socio Jurídicos*, Bogotá, Colombia, Estud. Socio-Juríd, 2020, p. 270.

⁶⁰ López Alfonsín, Marcelo, Berra, Elizabeth y Sparaccarotella, Sabrina, *La incorporación de los derechos de incidencia colectiva en el proceso judicial*, Editorial Jusbares, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2018, p. 82.

Las sentencias en el “*Caso Mendoza*” y “*Villa La Dulce*” resultan ser interesantes ejemplos de la eficacia que adquieren las mesas de diálogos y la realización de audiencias públicas como estrategias a partir de las cuales, con la colaboración de actores relevantes, es posible coadyuvar para arribar a un consenso integral. Estas experiencias nos demuestran la importancia de analizar permanentemente la posibilidad de combinar las estrategias de exigibilidad jurídica con distintos espacios de negociación política y social.

Citar: elDial DC332F

copyright © 1997 - 2023 Editorial Albrematica S.A. - Tucumán 1440 (CP 1050) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina